

1500178-73.2020.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo. Tal entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500178-73.2020.8.26.0550 -
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500178-73.2020.8.26.0550 - 2020/000365

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO DE CARVALHO e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

JOÃO PEDRO DE CARVALHO e DANIEL DAS NEVES LEITE foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 12 de junho de 2020, por volta das 23h30min, na Rua 24, com a Avenida 38, Jardim Santa Eliza, nesta Comarca, JOÃO PEDRO agindo em concurso e com identidade de propósitos com Daniel, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo e guardava 84 (oitenta e quatro) porções da substância

entorpecente denominada tetraidrocanabinol, totalizando aproximadamente 80 gramas, e DANIEL agindo em concurso e com identidade de propósitos com João Pedro, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardava 01 (uma) porção na forma de tijolo da mesma substância entorpecente, apresentado peso líquido de 436,22 gramas, outros 15 (quinze) tabletes da mesma substância entorpecente, totalizando aproximadamente 80 gramas, e mais 301 (trezentos e um) invólucros da mesma substância entorpecente, totalizando aproximadamente 320 (trezentos e vinte) gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 26 e laudo de constatação de fls. 32/35, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 110/112).

Regularmente notificados (fls. 151, 153), seguiram-se oferecimento de defesas preliminares em favor dos acusados (fls. 145/147, 158/159), sendo posteriormente recebida a denúncia em 29 de outubro de 2020 (fls. 165/168).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e duas de defesa, seguindo-se os interrogatórios dos acusados (fls. 218).

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base de JOÃO PEDRO no mínimo legal, em razão da primariedade, possibilitando a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional inicial aberto em caso de reconversão. Em relação a DANIEL, reclamou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida em sua moradia e indicação de dedicação a atividade criminosa, agravando-se em razão da recidiva específica, fixando-se regime prisional inicial fechado. Por fim, requereu seja decretado o perdimento da importância em dinheiro equivalente a R\$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) localizada no interior da pochete de JOÃO PEDRO e a R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais) apreendida na moradia de DANIEL (fls. 218).

O ilustre defensor de DANIEL, a sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do que disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, reclamou a fixação da pena no mínimo legal (fls. 219/224 acompanhada dos documentos de fls. 225/226).

A i. Defesa de JOÃO PEDRO, a sua vez, dizendo insuficiente a prova produzida, requereu a absolvição, nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, reclamou a fixação da pena-base no mínimo legal, com aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fixação de regime prisional aberto em caso de reconversão e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 234/246).

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se aos acusados a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c/c as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque agindo em concurso e com identidade de propósitos, levavam consigo, guardavam e tinham em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no auto de exibição e apreensão de fls. 26, no laudo de constatação de fls. 32/33 e no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 125/128, identificando-se na substância apreendida o elemento tetraidrocanabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha

Controverte-se sobre a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Ouvido em Juízo, o acusado JOÃO PEDRO negou a prática delitiva ou a posse de entorpecentes. Relatou que, na data dos fatos, estava saindo da moradia de DANIEL, quando verificou que o corréu já estava sendo abordado pelos Policiais Militares, na via pública. Afirmou que portava apenas quantia em dinheiro equivalente a aproximadamente setenta e cinco reais, além de seu aparelho celular. Acrescentou que não foi apreendido material ilícito em sua residência ou na de DANIEL, só tendo

avistado o entorpecente na delegacia de polícia, desconhecendo sua origem (fls. 218).

O acusado DANIEL, a sua vez, esclareceu que estava saindo de sua moradia junto a JOÃO PEDRO, quando avistaram a viatura policial se aproximando. Foram, então, abordados, sendo o interrogado levado para o interior da residência, onde passou a ser agredido e ameaçado de ser preso. Negou que houvesse qualquer material entorpecente em sua moradia, ou junto ao corréu. Por fim, afirmou desconhecer a apreensão de qualquer quantia em dinheiro em sua moradia (fls. 218).

Todavia, as versões deduzidas pelos acusados foram contrariadas pelas provas produzidas.

De fato, os Policiais Militares Alessandro e Diego, reiterando o que exposto inicialmente, afirmaram que na ocasião dos fatos estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado JOÃO PEDRO. Com a aproximação da viatura, ele tentou se abrigar na garagem de um imóvel, por isto que foi realizado acompanhamento, visualizando-se quando ele descartou ao solo uma pochete, no interior da qual foram apreendidas 82 (oitenta e duas) porções de maconha e a quantia em dinheiro de R\$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais). O acusado admitiu que estava realizando o tráfico de entorpecentes e que o acusado DANIEL, que posteriormente foi abordado defronte àquele imóvel, na via pública, seria seu fornecedor. Acrescentou, ainda, que possuía mais substância entorpecente em sua residência. Em diligências pela moradia de DANIEL -- que também admitiu a prática delitiva --, foram apreendidos 15 (quinze) tabletes de maconha, trezentas e uma porções do mesmo entorpecente, já embaladas e contendo as mesmas características daquelas inicialmente apreendidas, além de um facão utilizado para fracionamento do material ilícito, ao lado de uma peça maior da substância entorpecente, e a quantia em dinheiro de aproximadamente R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais). Na moradia de JOÃO PEDRO, que se situava nas proximidades, autorizado o ingresso pela genitora dele, foram apreendidas, em seu quarto, duas porções de maconha idênticas às anteriormente localizadas (fls. 218).

Como se tem rotineiramente consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais militares envolvidos nas diligências que culminaram na apreensão do entorpecente. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

A apreensão do entorpecente conjugada às circunstâncias em que se deram as prisões em flagrante revelam, inequivocamente, que estavam os acusados dedicados a atividade ilícita.

Deste modo, suficientemente evidenciada a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido naquela pochete descartada por JOÃO PEDRO e nas moradias

dos acusados, incontornável a prolação de decreto condenatório, inclusive com a incidência da pena de perdimento sobre a quantia em dinheiro apreendida, a revelar vínculo com a empreita delitiva.

Isto considerado, passo à dosagem das penas.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias judiciais e pessoais favoráveis, não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, cuidando-se tão somente de maconha, de menor potencial lesivo, possível seja fixada a pena-base a ambos os acusados no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em função da recidiva específica (fls. 123), a pena-base cominada ao acusado DANIEL deve ser majorada em 1/6 (um sexto), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Também em razão da recidiva, não se mostra possível o reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Já em relação ao acusado JOÃO PEDRO, possível a incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Conquanto se tenha apreendido com o acusado várias porções de entorpecente, não se reuniram elementos probatórios suficientes que evidenciassem estivesse ele dedicado à atividade mercantil ou se se tratava de envolvimento ocasional, sendo primário. Assim, deve a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 "caput" e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo. Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016). Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06). Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a

reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda.

Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Desta forma, pelos princípios acima indicados, ressaltando o posicionamento contrário deste julgador, a fim de evitar decisões contraditórias, que mais se potencializam em sede de jurisdição que alcança território mais reduzido, evidenciando desigualdade bastante gravosa, cumpre a este juízo também se alinhar à jurisprudência do Pretório Excelso.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e:

i) com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado JOÃO PEDRO DE CARVALHO à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, além da pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo; e

ii) com fundamento no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal, CONDENO o acusado DANIEL DAS NEVES LEITE à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato.

Por fim, decreto o perdimento da quantia apreendida em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena de DANIEL, seja por conta da recidiva, seja em função da natureza hedionda do delito, deverá ser o regime prisional fechado.

Sobre isto, cumpre dizer que a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispõe o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena. Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, promanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e

considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênia, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênia, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interditada a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descurar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado DANIEL deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, facultando-se, entretanto, a interposição de recurso em liberdade, se por outro processo não se encontrar preso, já que permaneceu solto no curso deste processo.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em relação a DANIEL e promovam-se os registros das condenações definitivas no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA